Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810520

Processo nº **0133993-39.2022.8.17.2001**

AUTOR(A): VANESSA ZACCHE DE SA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL– INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por VANESSA ZACCHE DE AS., em face de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, todos qualificados e representados.

Aduz, em síntese apartada, que é portadora de **Vasculite** com comprometimento da função renal e que, diante da análise clínica, o seu médico assistente prescreveu a realização de tratamento com **Rituximabe**, na dose de 500 mg no d1 e d15, seguido de uma nova infusão com 500mg nos meses 6, 12 e 18, conforme laudo (Id nº 117636504); que o plano de saúde réu negou a autorização ao tratamento sob a fundamentação de que a lei exclui da cobertura tratamento *off label*.

Requer concessão **da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional** para que seja a ré compelida a autorizar imediatamente o tratamento proposto pelo médico assistente. Ao final, requer a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e do reembolso na forma simples no montante de R$ 15.460,37 (quinze mil, quatrocentos e sessenta reais, e trinta e sete centavos), referentes ao primeiro ciclo do medicamento.

Decisão em que restou **indeferida liminarmente a antecipação da tutela** (Id. 117876985).

Malote digital com a decisão proferida em sede de agravo de instrumento (n. 0023338-52.2022.8.17.9000, Id. 122332720) *determinando que a seguradora que cubra o tratamento prescrito pelo médico assistente.*

Oportunamente a parte ré apresentou **contestação** (Id. 125686283) na qual requer preliminarmente a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor por ser uma entidade de autogestão. No mérito alega que o medicamento solicitado (Rituximabe) não possui indicação para tratamento da doença diagnosticada na parte autora, sendo assim, um medicamento de uso experimental; que eventual procedência da ação implica violação de decisões dos tribunais superiores, quebra de segurança jurídica e equilíbrio econômico do contrato.

Réplica (Id. 128384517).

As partes não pugnaram por produção de outras provas além das apresentadas nas manifestações respectivas.

É o relatório, sucinto.

Passo a decidir.

Ressalto, de início, que o presente feito comporta julgamento antecipado, pois sendo a questão de mérito de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, acho-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto ao seu mérito, nos moldes do art. 355, I, segunda parte do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico ser incontroverso que a ré é uma instituição que funciona como operadora de plano de saúde na forma de autogestão e, por essa razão, não incide nesta demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que o pedido inicial é improcedente.

O cerne da questão posto em análise é decidir se tem a parte ré **obrigação de dar cobertura tratamento *off-lable*** de conformidade com as cláusulas contratuais, considerando-se, também, o conteúdo da Lei 9.656/98.

Nas ações de plano de saúde, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Em assim sendo, da mesma maneira que os descumprimentos, por parte das operadoras de planos de saúde, das cláusulas contratuais desequilibram a avença originariamente pactuada impondo ônus excessivo a uma das partes, também o é a pretensão do segurado de obter benefício que não está previamente estipulado no contrato, e muito menos previsto em lei.

A consequência disso é a proliferação de demandas judiciais que poderia ser evitada pelo simples cumprimento contratual.

Ademais, para que o sistema privado de assistência à saúde seja mantido, é necessário que as obrigações de ambas as partes estejam claramente dispostas no contrato e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Importa salientar que, embora o Poder Judiciário não deva e nem possa fechar os olhos às mazelas sofridas pela população e, especificamente, pelas partes que trazem suas contendas e irresignações para julgamento, **não pode esse Poder querer impor às operadoras de plano de saúde o ônus de custear todo e qualquer procedimento**.

Nesse ponto, exsurge a importância do papel da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS na busca pelo equilíbrio nas relações existentes entre os usuários de plano de saúde e as operadoras.

Isso porque, antes da regulamentação do setor por intermédio da Lei 9656/98 e a criação da ANS pela Lei nº 9961/2000, as operadoras costumavam excluir dos contratos a cobertura para tratamento de diversas doenças, além de limitar o número de consultas médicas, dias de internação, sessões de fisioterapia, exames, idade para ingresso e até mesmo estabeleciam prazo para permanência no plano.

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10º institui **o plano-referência de assistência à saúde** e estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. É por essa razão que existe o **Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde**, uma lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A ANS, então, com base no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.961, de 2000, passou a editar normativos, instituindo e atualizando um rol de coberturas mínimas a serem garantidas pelos planos de saúde.

O referido rol, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 465, de 2021, estabelece uma lista de procedimentos e exames taxativa, uma vez que permite a ambas as partes, seja o usuário, seja a operadora do plano, ter uma previsibilidade quanto às coberturas asseguradas. Interpretar de forma diversa implicaria em impor custos não previstos quando da contratação do plano de saúde.

Atualmente há cerca de 3300 procedimentos de cobertura obrigatória. Pelo que não assiste razão a qualquer alegação de que este rol é exemplificativo (http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-rol-de-procedimentos (http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-rol-de-procedimentos).

O rol de procedimentos é revisado com a participação de um grupo técnico composto por representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de saúde, de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da ANS.

Isso não significa que todos os planos estão limitados a cobrir apenas o que consta na Resolução Normativa referida, mas sim que tratamentos/procedimentos adicionais deverão constar expressamente no contrato.

É dizer, o Rol de Eventos em Saúde da ANS não é meramente exemplificativo.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgamento do EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, decidiu que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS não deve ser visto como meramente exemplificativo e fixou a seguinte tese:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, ainda que por fundamentação diversa, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Nesse ponto, importa ressaltar que embora caiba ao médico assistente a decisão acerca do melhor tratamento, e conquanto haja tal liberdade, não se pode exigir da prestadora de serviços médicos que seja incumbida do pagamento de tratamento não previsto no contrato celebrado nem no Rol da ANS.

Nesse sentido, os enunciados 21 e 23 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça instrui os magistrados a:

Enunciado n.º 21
Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.o 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.

Enunciado n.º 23
Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.

Pois bem, no que diz respeito especificamente ao caso dos autos, os art. 17, §único, I, c, e 24 da RN 465 estabelecem:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998:
Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:
(...)
c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;
(...)
Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, desde que:
I - a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; e
II - a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

Registro que tratamentos médicos *off label* são aqueles em que utilizam materiais ou fármacos fora das indicações em bula ou protocolos e correm por conta de cada médico que o prescreve ou executa e também que não é o simples fato de serem *off-label* que importa em não cobertura; há hipóteses de cobertura de medicação fora da bula, mas é preciso demonstrar que a Conitec demonstrou eficácia cientifica ou que houve autorização para aquele uso pela Anvisa ao SUS, ambos ausentes no caso em análise.

Some-se a isso que a própria Lei 9656/98, alterada pela Lei nº 14.454/2022, passou a prever em seu art. 10, §§ 12 e 13 a extensão da cobertura para tratamentos fora dos incluídos no rol de cobertura obrigatória, excetuando o experimental vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Com efeito, não há nos autos demonstração das exceções legais a atrair a cobertura requerida. Ressalto que um estudo mencionado pelo médico assistente, ausente dos autos, sem tradução, não demonstra nem comprova a eficácia do medicamento na forma prevista em lei, como também ser ausente dos autos qualquer documentação da CONITEC a respeito da medicação.

Assim que tendo em vista a expressa previsão legal de que podem as operadoras de planos de saúde excluir da cobertura do contrato **tratamento com medicamento off-label,** e não demonstrada nos autos as exceções que autorizariam a cobertura, a negativa de autorização objeto da demanda está autorizada em lei e albergada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa feita, nem por força do contrato objeto da demanda, nem por força da submissão ao Rol obrigatório de eventos em Saúde, está a parte demandada obrigada a custear o tratamento requerido. Assim que é improcedente o pedido de obrigação de fazer, assim como o pedido de reembolso.

E, embora não constatada nenhuma abusividade do plano de saúde réu no caso dos autos, não é demais trazer à baila o entendimento do intérprete da Lei Federal (no caso a Lei 9.656/1998) para situações como a dos autos:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROFISSIONAL APTO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MÉDICO. CIRURGIÃO DENTISTA. DÚVIDA FUNDADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 3. Hipótese em que a negativa em autorizar a realização de cirurgia buco-maxilo-facial decorreu de fundada dúvida sobre qual o profissional, médico ou dentista, estaria apto a prescrever e realizar o procedimento, tendo sido, ademais, afirmado na origem que não houve prejuízo ao tratamento realizado.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.569.212/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Isto posto, com base nos dispositivos legais antes **mencionados julgo improcedentes os pedidos**, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no Art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento da verba honorária **de 10% sobre o valor atualizado da causa.**

Publique-se. Intimem-se. Preenchidos os requisitos legais, arquivem-se.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito
34vcb1

Assinado eletronicamente por: LARA CORREA GAMBOA DA SILVA
06/12/2023 09:24:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 151295303

23120609242518300000147769805

IMPRIMIR GERAR PDF